

1500750-02.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500750-02.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500750-02.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092229/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 24075127 - 01º D.P.

AMERICANA, 2092229 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FABRICIO ALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

LUAN FABRICIO ALVES DOS SANTOS está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 04 de abril de 2022, por volta de 18 horas, na Rua das Azaleias, 550, bairro Cidade Jardim, nesta cidade, trazer com ele, para fins de tráfico, doze porções de cocaína, com massa de cinco gramas, embaladas separadamente, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, além da quantia de R\$ 50,00, substâncias essas que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia em 20 de junho de 2022, fls. 140/142, o réu foi citado (fls. 185).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se Defesa (fls. 127/134) e a Acusação (fls. 138/139).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e

autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 201/203).

A Defesa reclama a absolvição por falta de provas. O réu não foi surpreendido em atos de mercancia. O motociclista que realizava o "Disque", Jefferson, empreendeu fuga e deixou os entorpecentes com o acusado, que era mero usuário de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Para o caso de condenação, requer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer a revogação da prisão preventiva, recurso em liberdade, com aplicação das medidas previstas no art. 28, da Lei de Drogas (fls. 205/210).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Na fase policial, Luan preservou silêncio (fls. 07).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, Do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lanço aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não reservar-se para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Já no interrogatório judicial alegou que efetuou a compra do entorpecente. Foi até o local para comprar 'um pino'. Jefferson, o motociclista, era um traficante conhecido em todos os lugares. Ele vendia drogas no 'disk', na 'sua quebrada'. Estava em regime aberto, por isso evitava ir até as 'biqueiras'. Combinou com o Jefferson de se encontrarem na praça da Cidade Jardim. Abriu a sua pochete, iria pegar R\$ 10,00 para comprar o 'pino', enquanto ele soltou o restante das drogas dentro da sua pochete. Olhou para o lado, avistou a viatura. Jefferson 'saiu fora'. Ficou assustado e saiu andando. Ao ser abordado, falou para os policiais que comprou os entorpecentes, que era usuário de drogas. Não estava traficando, não vendia drogas, era usuário.

Trabalhava com catador de reciclagem, juntamente com o seu tio. Ganhava R\$ 80,00, por dia. Iria comprar um 'pino', do motociclista Jefferson. Não sabia informar o sobrenome ou o endereço de Jefferson.

A versão não convence.

O policial militar Reinaldo Simões esclareceu que patrulhavam pelo bairro Cidade Jardim, na Rua das Azaleias, sentido a praça, local conhecido pelo tráfico de drogas. Avistaram um homem, que conduzia uma motocicleta, em negociação com outro rapaz, que estava na calçada. Ao se aproximarem, a motocicleta saiu em alta velocidade, enquanto Luan foi em direção à praça. O suspeito foi abordado e revistado, ele tinha nas mãos uma cédula de R\$ 10,00. Na pochete, que carregava na cintura, encontraram doze porções de cocaína, além da quantia de R\$ 40,00.

Questionado, Luan confessou que praticava o tráfico de drogas, que havia vendido entorpecentes para o motociclista. Diante dos fatos, Luan foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, para deliberações da autoridade policial. O réu e o rapaz da moto estavam em uma conversa bem próxima, havia uma movimentação de mãos entre eles. A moto saiu em alta velocidade e o réu saiu andando até a praça. Ao abordarem Luan, localizaram a quantia nas mãos dele. Patrulhava na viatura, juntamente com

dois colegas de farda. Não perseguiram o motociclista que se evadiu, tiveram que optar por ir atrás da moto ou do Luan. Não havia possibilidade de separar a equipe, colocaria em risco a segurança dos policiais, por isso decidiram abordar o acusado. Wellington Cezar da Silva Pereira, outro militar, ratificando a versão do colega, lembrou-se de que patrulhavam pela Rua dos Lilases, no bairro Cidade Jardim. Avistaram na praça do bairro, um rapaz entregando algo para um motociclista. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, o motociclista saiu em alta velocidade, enquanto o acusado deixava o local, caminhava rapidamente. Luan foi abordado e submetido a revista. Ele segurava uma quantia, uma nota de R\$ 10,00 amassada, escondida na mão direita. Havia uma pochete em sua cintura, que continha em seu interior doze porções de cocaína, além de R\$40,00 (uma nota de R\$ 20,00 e duas de R\$ 10,00). Indagado, Luan admitiu que traficava no local. Deram-lhe voz de prisão e o encaminharam até a Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial ratificou a voz de prisão.

Observaram quando o acusado entregava algo para o motociclista, que saiu em alta velocidade. Ao ser abordado, Luan segurava uma nota de R\$ 10,00, toda amassada. A equipe era composta por três policiais. Como a moto saiu em alta velocidade, era mais fácil pegar o suspeito que caminhava pela praça, que era frequentada por várias pessoas. Durante a abordagem, não havia ninguém próximo do réu e do motociclista.

Sem embargo da negativa, a prova é robusta e incrimina ao réu.

Ele foi visto em ponto de tráfico, enquanto trocava objeto com outro homem, não identificado. Na pochete que trazia, ao depois apreendida, levava significativas porções de drogas (12 porções de cocaína). Também dinheiro, R\$ 10,00 nas mãos e R\$ 40,00 na pochete, típico da venda de drogas.

Imediatamente, confessou o crime, o que já tinha sido perfeitamente visualizado pelos policiais.

Os policiais, a respeito, deram versão coesa, convincente, inexistindo comprovação alguma de que o réu não tivesse vínculo com a droga, achada com ele, conforme relatado pelos agentes.

A versão de Policial Militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age

facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Bem certa, a prova, assim, quanto a efetiva ocorrência do tráfico. As circunstâncias da prisão em local já conhecido como ponto de tráfico; a apreensão das drogas, já embaladas em pequenas porções, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros; suspeitosa levada de dinheiro, sem procedência lícita provada, evidenciam que ele vinha se dedicando a essa atividade criminosa.

A quantidade e disposição, não permitem inferir conclusão outra senão a de que se destinassem ao tráfico.

Luan admitiu portar as drogas e os valores em dinheiro, mas negou estar traficando. A alegação de que não tinha qualquer envolvimento com os entorpecentes não foi provada e muito menos é crível, pelas circunstâncias já enfatizadas, em especial os depoimentos dos policiais e a comprova apreensão da droga e numerário.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que trazia com ele drogas, para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Também o fato de eventualmente ser usuário de drogas, não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

Por evidente, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e em que é irrelevante a quantidade da substância

apreendida (neste sentido, 5ª T. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, REsp 1.637.113). Também, a quantidade, nocividade e variedade de drogas afasta qualquer consideração a respeito de bagatela.

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo de constatação (fls. 13/15), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 64/66).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu registra condenações. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 0000232-09.2016.8.26.0630 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 § 4º, I, II c/c Art. 14, II ambos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/03/2017). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito. Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto, pelos maus antecedentes.

Na segunda, pela reincidência (Processo nº 0000164-25.2017.8.26.0630 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 33, "caput", do SISNAD; com trânsito em julgado para a Defesa em 11/09/2018). Exaspero a pena em mais um sexto. Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis. O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar LUAN FABRICIO ALVES DOS SANTOS, às penas de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, regime inicial fechado e seiscentos e oitenta (680) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I, do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 118).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico. Interessa as suas prisões para a eficaz aplicação da lei penal.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora;

Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

“Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo” (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Recomende-se o réu.

P.I.C.

Americana, 15 de agosto de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA